

第38問

甲は、先輩であるBから借金の返済を迫られていたが、手元に十分な財産がなかった。そこで、知り合いの資産家Aの家に侵入したところ、現金5万円と万年筆を発見した。甲は、万年筆の収集を趣味としていたため、現金5万円についてはBに対する借金の返済に、万年筆については自己のために持ち出すことにした。

甲が現金5万円及び万年筆を持ったままA宅を出ようとしたところ、玄関でAと鉢合わせてしまった。そこで、甲は、どうせならAを脅して、さらに現金等を奪おうと考え、Aに対して、所持していたナイフを示しながら、「金を出せ。」と申し向けた。Aは、甲から攻撃を受けて怯んだが、すぐにA宅を出て、大声で「泥棒だ。誰か警察を呼んでくれ。」と叫んだ。これに驚いた甲は、Aから現金等を奪うのを諦め、急いでその場から立ち去った。

その後、甲は現金5万円を封筒に入れ、メンディングテープで封をした上、封入部分に「B」と記載した（以下「本件封筒」という。）。

甲は、先輩であるBが日頃から甲ら後輩に対して粗暴な態度を示し、時には暴力を振るうことに恐怖心を感じており、直接Bに本件封筒を手渡すと、返済が遅れたことに怒りを感じたBから何をされるか分からないと考えた。そこで、友人の乙に、現金5万円がA宅から盗み出したものであることを秘して、Bに本件封筒を渡してもらうことを依頼した。

また、甲は、万年筆についても、しばらくは自分で保管しておくのはよくないだろうと思い、A宅から盗み出したことを秘して、乙に預かってもらうことを依頼した。

乙は、あまり気が進まなかったものの、甲の必死な様子を見てかわいそうになり、これらを預かった。

翌日、乙は、偶然、万年筆を見ると、「A」という刻印があり、万年筆がA宅から盗み出されたものであることに気付いた。しかし、乙は、Aが資産家であることから、万年筆が一つくらい盗まれてもかまわないだろうと考え、引き続き、甲のために保管することにした。また、乙は、封筒の中の現金は、口止め料としてもらっておこうと考え、本件封筒を破って、中に入っている現金5万円を取り出して自己の財布へ入れた。

甲及び乙の罪責について、論じなさい。

第1 甲の罪責

- 1 A宅に侵入して、現金5万円と万年筆を盗み出した点について、住居侵入罪（130前段）と窃盗罪（235）が成立することは、明らかである。

また、Aから現金等を奪うために、Aに暴行を加えた点については、強盗未遂罪（243、236Ⅰ）が成立する。

- 2 窃盗既遂後に、1項強盗の未遂が成立する場合の処理が問題となる（**論点** 居直り強盗）。

広島高松江支判昭32.5.27は、全体として1項強盗既遂と評価している。一方、大阪高判昭33.11.18、東京地判昭55.10.30は、このような処理を否定し、1項強盗は未遂にとどまるとした。

総合 210 頁 論証 91 頁

第2 乙の罪責

- 1 盗品保管罪の成否

まず、万年筆がA宅から盗み出されたものであることに気付きつつ、甲のために引き続き保管している行為について、盗品保管罪（256Ⅱ）の成否を検討することになる（**論点** 盗品等保管罪（256Ⅱ）における知情の時期 **論** 司R3,予H26,旧H4-2,H14-2）。

この点については、「赃物であることを知らずに物品の保管を開始した後、赃物であることを知るに至ったのに、なおも本犯のためにその保管を継続するときは、赃物の寄蔵にあたる」として、これを肯定するのが判例（最決昭50.6.12【百選Ⅱ76】）である。

総合 258 頁 論証 130 頁

- 2 窃盗罪の成否

(1) 次に、本件封筒の中に入っていた5万円を自己の財布へ入れた点であるが、封緘物の占有が受託者にあるなら横領罪（252）、委託者にあるなら窃盗罪が成立することになる（**論点** 封緘物の占有）。

総合 198 頁 論証 84 頁

(2) 判例（最決昭32.4.25、東京高判昭59.10.30【百選Ⅱ27】）は、包装物全体の占有は受託者に帰属しているが、中身は委託者に帰属していると解しているから、これに従って処理をすればよい。乙には窃盗罪が成立する。

(3) なお、この5万円は甲がA宅から窃取したものであるが、窃盗犯人から第三者がさらに窃取した場合にも窃盗罪が成立すると考えられている（**論点** 財産犯の保護法益論 **論** 司H27,予R3）。なお、横領罪の成否を検討した場合には、盗品についての横領罪の成否を検討することになるが、判例はこれを肯定する立場に立つと解されている（最判昭36.10.10参照）。

総合 193 頁 論証 81 頁

答案構成

第1 甲の罪責

- 1 住居侵入罪（130前段）及び窃盗罪（235）成立

↓

- 2 1項強盗未遂罪（243、236 I）成立

↓

既遂にはならない

↓

- 3 窃盗既遂罪は1項強盗未遂罪に吸収され、住居侵入罪とは、牽連犯（54 I 後段）となる

第2 乙の罪責

- 1 盗品保管罪の成否（256 II）

↓

知情後保管の成否

↓

保管途中から盗品等であることを認識した場合において、それ以降も本犯者のために保管を継続すれば同罪が成立する

↓

あてはめ

↓

- 2 本件封筒の中に入っていた5万円を自己の財布へ入れた点について、窃盗罪又は横領罪（252）の成否

↓

封緘物の占有

↓

あてはめ

↓

窃盗罪成立

↓

盗品である点は障害とならない

↓

- 3 盗品保管罪と窃盗罪は併合罪となる

第1 甲の罪責

1 A宅に侵入した点については、「正当な理由がないのに、人の住居……に侵入し」たものとして、住居侵入罪（130条前段）が成立する。また、現金5万円と万年筆を盗み出した点については、「他人の財物を窃取した」ものとして、窃盗既遂罪（235条）が成立する。

2(1) また、Aから現金等を奪うために、ナイフを示しながらAに「金を出せ。」と申し向けた点については、当該脅迫はAの反抗を抑圧するに十分なものであるから、「脅迫を用いて他人の財物を強取」（236条1項）しようとしたものといえる。もっとも、結局甲はAから現金等を奪うのを諦めているのだから、「これを遂げなかった」（43条本文）ものとして、少なくとも、1項強盗未遂罪（243条、236条1項）が成立する。

(2) さらに進んで、財物を取得した直後に脅迫が加えられているのであるから、全体として1項強盗罪の既遂と評価すべきとする説もあるが、脅迫と全く因果性のない財物取得をもって強盗罪の既遂と認めるのは無理がある。

したがって、1項強盗罪は未遂にとどまり、既遂罪としては処断できないと解すべきである。

3 よって、甲には、窃盗既遂罪と1項強盗未遂罪が成立するところ、両罪は、保護法益がAの財産権と共通しており、また2つの行為には時間的・場所的近接性及び連続性が認められるから、窃盗既遂罪は重い1項強盗未遂罪に吸収される。これと住居侵入罪とは目的・手段の関係にあ

1

るから、牽連犯（54条1項後段）となる。

第2 乙の罪責

1(1) まず、万年筆がA宅から盗み出されたものであることに気付いた後に、引き続き、甲のために保管した行為について、「盗品」（256条1項）を「保管」（同条2項）したものとして、盗品保管罪の成立が考えられる。

(2) 乙は、甲から万年筆を受け取った際には盗品であることを知らないのだから、故意（38条1項）が認められず、少なくともその時点では同罪は成立しない。

しかし、盗品等を保管すれば、被害者の追求権侵害の状態が継続し、その間保管行為も継続する以上、同罪は継続犯であるといえる。また、事後従犯的性格は保管後に盗品性を認識した場合でも異ならない。

したがって、保管途中から盗品等であることを認識した場合において、それ以降も本犯者のために保管を継続すれば同罪が成立する。

(3) 乙は万年筆を預かった翌日にこれがA宅から盗まれたものであることに気付いているのだから、それ以降も甲のために保管を継続した行為には、盗品保管罪が成立する。

2(1) 次に、本件封筒の中に入っていた5万円を自己の財布へ入れた点について、窃盗罪又は横領罪（252条）の成立が考えられる。

本件封筒そのものの占有が乙にあることは疑いなく、この点からすれば、5万円を領得する行為は、「自己の占有する他人の物を横領し

2

た」ものとして、横領罪を構成するとも思える。

一方で、本件封筒は封がされている上、封入部分に「ズ」と記載されており、中身を披見することは困難である。そうだとすれば、本件封筒の中の5万円の占有はいまだ甲にあるとも考えられる。このようにみた場合は、乙に窃盗罪が成立することになる。

では、いずれと解すべきか。

- (2) 上記のように、封緘物全体の占有が受託者にあることは明らかである。一方で、封緘があるとき、受託者は中身を披見できないから、内容についての事実上の支配は委託者にあると解すべきである。

したがって、包装物全体の占有は受託者に帰属しているが、中身は委託者に帰属しているとすべきである。

- (3) 本件で、本件封筒は前述のように中身を披見することは困難であるから、5万円の占有は甲にあるというべきである。よって、上記行為は、甲の占有を侵害したものとして、乙に窃盗罪が成立する。

なお、5万円は甲がA宅から窃取したものであるが、さらにこれを窃取する者との関係では、占有の要保護性は失われないと考えられるから、この点は、窃盗罪の成立において障害とならない。

- 3 以上より、乙には万年筆についての盗品保管罪と現金5万円についての窃盗罪の罪責を負い、併合罪（45条前段）となる。

以 上